

1500381-27.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... adolescente pelo envolvimento com o tráfico, defronte sua residência, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou evadir-se, mas acabou sendo abordado. Questionado, o réu acabou confessando aos policiais que no interior de sua residência havia drogas. Diante de tal informação e dos indícios da prática de tráfico de drogas no local, com o apoio de cão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500381-27.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500381-27.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040018/2022 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO HERMENEGILDO GIMENES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

VICTOR HUGO HERMENEGILDO GIMENES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 08h40min, na Rua Expedicionário Léllis nº 2858, Centro, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, guardava e tinha em depósito 1328,15g (um quilograma, trezentos e vinte e oito gramas e quinze centigramas), de cocaína na forma de "pedras crack", acondicionada em 14 (quatorze) invólucros plásticos, 129,78g (cento e vinte e nove gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína em pó, acondicionada em 02 (dois) invólucros plásticos, e 20,04g (vinte gramas e

quatro centigramas) também de cocaína em pó, acondicionada em 39 (trinta e nove) microtubos plásticos, do tipo "ependorff", para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, na data dos fatos, o acusado praticava o tráfico de drogas nesta cidade de Sertãozinho. No exercício da atividade ilícita, VICTOR HUGO guardava e tinha em depósito, no interior de sua residência, 14 (quatorze) pedras de "crack", 02 (duas) porções grandes e ainda não divididas de cocaína em pó e 39 (trinta e nove) eppendorfs contendo cocaína. Porém, Policiais Militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram o acusado, já conhecido enquanto adolescente pelo envolvimento com o tráfico, defronte sua residência, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou evadir-se, mas acabou sendo abordado. Questionado, o réu acabou confessando aos policiais que no interior de sua residência havia drogas. Diante de tal informação e dos indícios da prática de tráfico de drogas no local, com o apoio de cão farejador, os policiais militares acabaram encontrando na residência, mais precisamente sob a cama de VICTOR HUGO e no interior de uma mochila, as drogas acima mencionadas, além de petrechos para o preparo e embalagem da droga, tais como: sacos plásticos, balança de precisão, 110 (cento e dez) microtubos e um aparelho celular. VICTOR HUGO foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para as medidas legais cabíveis, onde foi interrogado e admitiu ter adquirido a droga por R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para revender.

A denúncia foi recebida em 16 de março de 2022 (fls. 155/157), o réu foi citado (fls. 181) e apresentou resposta à acusação (fls. 188/189).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como uma testemunha arrolada pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa do acusado, por sua vez, alegou preliminares de cerceamento de defesa, violação à garantia de incomunicabilidade das testemunhas e violação de domicílio. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação de pena base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial aberto, substituindo-se, ainda, a pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, urge o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa.

Destaco que o indeferimento da oitiva da menor Maria Vitória Damacena Hermenegildo, irmã do réu, deu-se de maneira justificada. Isso porque, conforme já salientado, a alegação de que VICTOR HUGO sofreu violência física pelos policiais militares não encontra respaldo em qualquer elemento mínimo probatório disposto nos autos, tendo em vista que o próprio réu, em sede policial, negou ter sofrido qualquer violência física pelos agentes (cf. fls. 07) e não restou comprovada qualquer agressão a ele (cf. declaração médica de fls. 28), ficando ratificados, portanto, os motivos expostos na decisão de fls. 250/251.

Neste sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes (STJ, REsp n. 1.519.662/DF). 2. O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha, quando motivado, não configura cerceamento de defesa, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador (STJ, AgRg no REsp n. 1.498.225/RS). 3. O deferimento de provas submete-se ao arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, deve levar em conta o conjunto probatório (STF, RHC n. 90.399/RJ). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 158682 SP 2021/0405711-0,

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (grifei)."

Neste ínterim, não houve, portanto, cerceamento de defesa.

Quanto à preliminar de violação à garantia de incomunicabilidade das testemunhas arguida pela Defesa, também reputo adequado seu afastamento.

Ressalto que não há comprovação de efetivo prejuízo na realização da audiência por videoconferência em relação à oitiva do policial militar Paulo Roberto. A razão de o agente ter sido ouvido em sua residência se deve tão somente ao fato de que reside em outra comarca (Jardinópolis) e seu deslocamento até a presente comarca se torna dispensável, mormente se consideradas as medidas de contenção aos efeitos da pandemia e o decreto do Governo Estadual determinando o mínimo deslocamento de pessoas. Assim, ainda que a testemunha não tenha comparecido presencialmente ao Fórum, destaco que foram tomados todos os cuidados necessários para manter a incomunicabilidade dos agentes, inclusive manifestados pelo requerimento de que Paulo ligasse sua câmera para que pudesse ser ouvido em Juízo, tendo sido ouvido sem a presença de qualquer outra pessoa no recinto onde estava. Seria impossível ainda se presumir que as testemunhas policiais teriam discutido previamente sobre os fatos, de forma a contaminar o próximo depoimento, motivo pelo qual afasto tal preliminar.

Quanto à preliminar arguida pela Defesa de violação de domicílio do acusado e consequente alegação de prova ilícita, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, também reputo adequado seu afastamento.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução, restou claro que VICTOR HUGO foi avistado em frente à sua residência, em atitude suspeita, sendo que, quando notou a presença da viatura policial, tentou evadir-se para dentro do imóvel. Dadas as circunstâncias dos fatos, os agentes conseguiram abordá-lo. Em que pese nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, havia situação de justa causa a indicar a situação de flagrante delito a possibilitar a entrada dos policiais no imóvel, tendo em vista que o próprio réu franqueou a entrada dos agentes no local e acompanhou a diligência policial, conforme narrativa dos policiais militares em Juízo. Não bastasse, VICTOR HUGO, inclusive, narrou em Juízo ter confessado a guarda e depósito de drogas no imóvel e que indicou aos agentes o local em que os entorpecentes se encontravam, atitude que, por si só, deduz-se na permissão de entrada no imóvel pelos agentes. Assim, infere-se que não houve ingresso forçado dos policiais na residência do réu: a porta da residência estava aberta, VICTOR HUGO agia em atitude suspeita (como se estivesse esperando a chegada de "clientes"), o local era conhecido como ponto de tráfico de drogas e houve tentativa de evasão do réu.

Ademais, conforme será analisado na sequência, havia significativa quantidade de droga armazenada no imóvel do réu, caracterizando o delito de tráfico, o qual é de natureza permanente, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser reconhecida no flagrante, conforme inclusive recentemente decidiu o E. STF:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta

a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido." (RHC 213852 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

Logo, também não prospera a alegação de violação de domicílio e consequente pedido de desentranhamento dos autos por suposta obtenção de prova ilícita na ocasião. Quanto ao mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelas imagens fotográficas (fls. 13/19), pelo auto de constatação preliminar (fls. 20), pelo laudo toxicológico (fls. 131/135), pelos laudos químico-toxicológico (fls. 136/138 e 139/141), conclusivos por se tratar de cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e repousa sobre o acusado.

As testemunhas policiais militares Edgar e Paulo, ouvidos na fase policial, declararam que estavam em patrulhamento pelo local quando avistaram o acusado, já conhecido enquanto menor pelo envolvimento com o tráfico de drogas, em frente à casa dele. Ao ver a viatura, tentou evadir-se, sendo alcançado e abordado. Consigo, nada de ilegal foi localizado. Indagado, disse que havia drogas na casa, porém não indicou exatamente onde. Com apoio de cão farejador, foi possível encontrar, sob a cama do acusado, uma mochila, dentro da qual estavam as drogas e petrechos. Ele alegou que havia adquirido as drogas em Ribeirão Preto, de pessoa que não quis declinar, por R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e as estava revendendo (fls. 05 e 06).

Em Juízo, a testemunha policial militar Edgar declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Alvorada, juntamente com seu colega Paulo, quando avistaram VICTOR HUGO, o qual era conhecido por seu parceiro pelo envolvimento com tráfico de entorpecentes na adolescência. Quando a viatura se aproximou, o réu, que estava sentado na porta de sua residência, tentou evadir-se para dentro do imóvel, porém sem sucesso. Abordado, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Após, questionado se havia drogas na residência, o réu admitiu que havia entorpecentes no imóvel, mas não indicou o local. Assim, foi chamado o apoio do canil, sendo necessário cão farejador, momento em que encontraram, no quarto do réu, debaixo de sua cama, uma mochila contendo as drogas apreendidas. Havia tanto cocaína à granel, como em pinos, assim como pinos vazios e porções de crack. Também foram encontrados uma balança de precisão, sacos plásticos e eppendorfs vazios no imóvel. Em seguida, o réu admitiu que comprou a droga em Ribeirão Preto, por R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois estava precisando de dinheiro. Disse que não havia mais ninguém na residência (v. mídia).

Em Juízo, a testemunha policial militar Paulo declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Alvorada, juntamente com seu colega Edgar, quando avistaram VICTOR HUGO, o qual era conhecido pelo envolvimento com tráfico de entorpecentes na adolescência. Destacou que o bairro é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Quando a viatura se aproximou, o réu, que estava sentado na porta de sua residência, que estava aberta (tratava-se de um portão único), tentou evadir-se para dentro do imóvel, porém sem sucesso. Abordado, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Fizeram entrevista pessoal com o réu e este acabou confessando que havia drogas no interior da residência. Ao adentrarem o local, VICTOR HUGO os acompanhou e permitiu a entrada dos agentes, autorizando a revista domiciliar, momento em que encontraram as drogas apreendidas dentro de uma mochila, embaixo de sua cama. Ressaltou que necessitaram de ajuda de cão farejador para encontrarem os entorpecentes. Disse que havia pedras de crack, cocaína à granel, pequenas porções de pasta base de cocaína, pinos de cocaína, eppendorfs vazios e uma balança de precisão. Destacou que somente ao final da ocorrência é que chegou uma irmã menor do réu, cerca de 9/10 anos de idade, assim como a genitora do réu. Após dada voz de prisão a VICTOR HUGO, ele foi levado à UPA, não sendo identificada qualquer lesão e, após, ao plantão policial. Disse que o réu foi bem solícito e que cooperou com eles. Por fim, afirmou que já abordou o réu várias vezes em ocasiões anteriores quando ele ainda era adolescente, pelos mesmos fatos (tráfico de drogas) (v. mídia).

Em Juízo, a testemunha Elaine, arrolada pela Defesa, declarou ter sido vizinha do réu, desde quando ele tinha cerca de 4 ou 5 anos, morando na rua acima da casa dele, mas que se mudou para outro bairro há cerca de dois meses. Na data dos fatos, ainda era sua vizinha e estava indo à padaria, quando notou que havia muitas viaturas em frente à casa do réu. Viu mais de 4 viaturas da guarda municipal e disse que, depois, também chegaram cerca de 4 ou 5 viaturas da polícia militar. Quando se aproximou, notou que havia agentes tanto na parte interna do imóvel, quanto na parte externa. Disse que o réu não estava na frente do imóvel e que estava dentro da casa junto com sua irmã menor e que VICTOR HUGO saiu da residência junto com os policiais. Chegou a dizer aos policiais que a genitora do réu não estava na residência. Entende que os policiais militares invadiram o local sem autorização. Por fim, disse ter conhecimento de que o réu já foi internado na Fundação Casa, mas não sabe por quanto tempo (v. mídia).

O réu, ao ser interrogado na fase policial, negou a prática delitiva, alegando ser usuário de "maconha". Sobre os fatos, alegou que, até 15 dias atrás, trabalhava em uma serralheria em São José do Rio Preto com seu pai. Disse que retornou a Sertãozinho e que ficou sem dinheiro, razão pela qual resolveu vender drogas. Adquiriu em Ribeirão Preto, de pessoa que não quis informar, R\$30.000,00 (trinta mil reais) em entorpecentes (cocaína e "crack"), "no prazo", ou seja, para pagamento posterior. Revenderia tais drogas para obter lucro. Deste valor, já havia quitado R\$2.000,00 (dois mil reais), restando, portanto, R\$28.000,00 (vinte e oito mil reais) a serem pagos. Disse que, na data dos fatos, policiais militares o abordaram e, na sequência, encontraram em sua casa as drogas ora apreendidas. Afirmou já ter sido detido com drogas enquanto menor, inclusive dizendo já ter sido internado na Fundação CASA por duas vezes, ambas por tráfico de drogas (fls. 07). Em Juízo, o réu declarou não ser verdade que foi enquadrado em frente à sua residência na data dos fatos. Esclareceu que, na presente data, havia chegado em sua casa por volta de 06h00min, vindo de uma festa. Disse que sua mãe saiu para trabalhar e pediu para que trancasse a porta, o que o fez. Por volta de 08h30min, vários policiais entraram na residência (cerca de oito ou nove agentes), pois disseram que havia denúncias de que no local estava sendo praticado o tráfico de entorpecentes. Afirmou que os agentes o abordaram com agressão, batendo e retirando-o do beliche (ele estava em cima e sua irmã mais nova embaixo), sendo que os agentes tiraram sua irmã do imóvel. Pediu para falar com a testemunha policial Paulo, tendo em vista que este o persegue há tempos. Disse a ele que havia entorpecentes no local, já que ele estava envolvido em um "BO", necessitando de dinheiro. Ressaltou que não foi o cão farejador que encontrou os entorpecentes, mas que, pelo contrário, ele mesmo que os indicou aos agentes, dizendo que estavam embaixo da cama de sua mãe. Disse que pegou as drogas para guarda na segunda-feira, 07 de fevereiro, e que ganharia R\$600,00 (seiscentos reais) por semana - iria receber esse dinheiro na data dos fatos, às 17h00min. Esclareceu que estava em débito com a pessoa que lhe pediu para guardar os entorpecentes em sua residência, visto que havia batido um carro dela e foi detido por policiais em ocasião anterior. Por fim, disse que já foi internado na Fundação Casa por duas vezes, a primeira por 8 (oito) meses e a segunda por 30 (trinta) dias, ambas em razão do tráfico. Afirmou que está sendo perseguido pelo policial Paulo Caetano, que não pode vê-lo na rua, e que, inclusive, tem um processo aberto em face dele por abuso de autoridade. Ressaltou que estava trabalhando em uma serralheira antes de vir para a cidade (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o réu era realmente o proprietário das drogas apreendidas e que estas se destinariam à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram VICTOR HUGO, já conhecido enquanto menor pelo envolvimento com o tráfico de drogas, em frente à sua residência. Ao avistar a viatura, o réu tentou

empreender fuga, mas foi detido pelos policiais, não logrando êxito. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Contudo, em sua residência, com apoio de cão farejador, foi encontrada, sob a cama do réu, uma mochila, dentro da qual estavam as drogas apreendidas e petrechos.

O réu, por sua vez, confessou a prática delitativa, admitindo que adquiriu R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em drogas, sendo elas cocaína e "crack", a prazo, de terceiro, com o escopo de revendê-las para obter lucro. Na data dos fatos, permitiu a entrada dos agentes em sua residência, momento em que foram encontradas em seu quarto as drogas apreendidas. Em juízo, mudou parcialmente a versão apresentada na serra policial, asseverando que foi ele mesmo quem indicou o local das drogas e que fazia sua guarda a mando de terceira pessoa não indicada, com a qual possuía uma dívida.

A novel versão posta em Juízo não infirma a convicção judicial, eis que, não obstante a possível discrepância sobre os motivos pelo qual guardava as drogas, se eram ou não de sua propriedade, bem como a forma como se deu a localização dos entorpecentes, com ou seu auxílio do increpado, é certo que o acusado mantinha em seu poder quantidade significativa de drogas, devidamente acondicionadas para o exercício de mercancia. Além disso, considerado se tratar de infração penal do tipo misto alternativo, sua consumação se dá com a realização de qualquer dos verbos previstos em seu preceito secundário, razão pela qual não restam dúvidas sobre a materialidade e autoria convergente em desfavor do réu quanto ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei de Drogas.

Assim, considerando a significativa quantidade de drogas encontradas no interior da residência do réu, superior ao que normalmente é encontrado com meros usuários, bem como a forma como estavam acondicionadas, sobretudo porque no local foram encontrados petrechos comumente utilizados para preparo e embalo de drogas, e sopesando o fato de que VICTOR HUGO também já era conhecido nos meios policiais pela traficância, conclui-se que as drogas apreendidas efetivamente eram destinadas ao tráfico de entorpecentes.

Ademais, ressalto que fora encontrada grande quantidade de entorpecentes: 1328,15g (um quilograma, trezentos e vinte e oito gramas e quinze centigramas), de cocaína na forma de "pedras crack", acondicionada em 14 (quatorze) invólucros plásticos, 129,78g (cento e vinte e nove gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína em pó, acondicionada em 02 (dois) invólucros plásticos, e 20,04g (vinte gramas e quatro centigramas) também de cocaína em pó, acondicionada em 39 (trinta e nove) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf", fatos que representam intenso perigo à saúde pública, a ensejar um decreto condenatório.

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos. Não havendo qualquer indício nos autos quanto à suspeição desses agentes públicos, estes depoimentos são aptos como meio de prova:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase

investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Coeso testemunho dos policiais militares - Validade - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Assim é que não se contesta a validade dos dois depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória e consequente absolvição do acusado nos termos do art. 386, II, do

Código de Processo Penal.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, além de ser confesso, porém tais circunstâncias atenuantes não tem o condão de fazer com que a pena seja reduzida aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Em que pese não deva ser levada em consideração tão somente a quantidade e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cocaína e crack) para a aplicação ou não da referida causa de diminuição de pena, há que se considerar o fato de que VICTOR HUGO apresenta antecedentes na Vara de Infância e Juventude, tendo sido internado por duas vezes em razão de envolvimento com ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes (cf. fls. 247). Embora atos infracionais pretéritos não sirvam para fixar maus antecedentes ou reincidência, servem como fundamento válido para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme já decidido pelos tribunais superiores (EResp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção). O réu também deixou de comprovar, por prova idônea, o exercício de atividade remunerada lícita, indicando que praticava o tráfico para se sustentar, de forma reiterada.

Assim, por tais motivos, merece ser duramente apenado e não pode ser beneficiado com a diminuição máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva as penas fixadas.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional. ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair

da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta à ré, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o

patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VICTOR HUGO HERMENEGILDO GIMENES, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Não havendo alteração do panorama fático e jurídico desde a liminar concedida em sede de Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, folha 167/171, estando o acusado solto desde então, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 20 de outubro de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA